

1502689-70.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... pelo delito de associação para o tráfico. Precedentes (STJ, Habeas Corpus 440016/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. 07/06/2018).

PELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas - Absolvição do artigo 35, da Lei 11343/06. Tráfico de entorpecentes: Firmes, coerentes e seguros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502689-70.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502689-70.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322523/2021 - DEL.POL.SERRANA, 21629949 - DEL.POL.SERRANA, 1493/21/427 - DEL.POL.SERRANA, 2322523 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON HUGO DA COSTA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

ANDERSON HUGO DA COSTA e CLEBER FERNANDO DA COSTA, ambos já qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 11h30, na Rua Goiás, nº 352, Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca, agindo associados e com identidade de propósitos, tinham em depósitos e ocultavam, para fins de entrega a terceiros, 23 (vinte três) eppendorfs contendo no total 6,930g (seis gramas e novecentos e trinta miligramas) da substância entorpecente cocaína em pó e 11 (onze) porções contendo no total 1,560g (um grama e quinhentos e sessenta miligramas) da substância entorpecente cocaína em forma de crack, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), laudo de constatação

provisória (fls. 40/42), fotografia das drogas (fls. 33/37) e exame químico-toxicológico (fls. 113/115), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 143/145).

A denúncia foi recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 156/157).

Durante a fase instrutória foram ouvidas as testemunhas de acusação, bem como realizado o interrogatório do réu (fls. 205/206).

Em sede de memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, a fim de condenar os acusados aos crimes supracitados na denúncia (fls. 214/221).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado Anderson Hugo da Costa, alegando absoluta ausência de prova da autoria. Sobre o acusado Cleber Fernando da Costa, pugnou pela aplicação do benefício da confissão espontânea (fls. 233/234).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), exame químico-toxicológico (fls. 113/115), como também pelas provas orais trazidas aos autos.

A autoria também é certa e incontestável.

A investigadora da Polícia Civil Dayanne Duarte Silva Sakamoto, testemunha da acusação, declarou em juízo que a investigação começou após a denúncia de um morador da Travessa Nossa Senhora de Fátima, tendo o mesmo informado os investigadores que dois gêmeos, juntamente com a pessoa de Welinton, estavam traficando dia e noite no local, sendo que os demais moradores do endereço, a maioria idosos, estavam com medo, pois a atividade ilícita realizada no local estava atraindo diversos jovens que muitas vezes iam até a travessa de moto e bicicleta. Relatou a testemunha que após essa denúncia foi realizada diligência, tendo restado concluído, de forma muito clara, que estava ocorrendo o tráfico no local informado através da denúncia. Informou que na época dos fatos ainda era realizado plantões na delegacia e que por ventura, em um determinado dia por volta das 20 horas, a mesma passou de viatura e avistou os dois gêmeos sentados próximos a travessa, debaixo de uma árvore e em um local de pouca iluminação, mas bastou o tempo dela fazer o retorno com a viatura, com o intuito de filmar os irmãos, visto que ela já estava investigando os mesmos, para que eles saíssem do local. Disse que obteve a informação de que os acusados residiam em um local e por serem reincidentes nos crime de tráfico, roubo e furto, guardavam a droga em outro lugar, mais especificamente na residência da mãe dos gêmeos, sendo que eles faziam isso com o intuito de não chamar a atenção. Informou que quando a investigação estava quase terminando, recebeu uma denúncia anônima dizendo que o acusado Cleber tinha sido avistado com uma sacola que continha, aparentemente, pinos de cocaína, tendo a investigação se encerrado após essa última denúncia. Sobre o dia em que foi efetuada a busca, a testemunha informou que estava na equipe que ingressou na residência da Rua Goiás, dizendo que chegou até o local em viatura descaracterizada e encontrou ambos os gêmeos e uma adolescente sentados em frente à casa, mas que nenhuma droga foi encontrada na posse deles ou na residência, exceto uma trouxinha de maconha que estava com a adolescente, que disse que a droga era de seu uso pessoal. Declarou que foi realizado busca com o auxílio do canil em duas casas, pois existiam duas casas dentro de um mesmo terreno, e que dentro do quarto de Cleber o cachorro manifestou sinal de que havia alguma substância no local, tendo sido encontrado as drogas dentro do colchão. Relatou que Cleber assumiu a posse das drogas, mas que depois, ao ser informado que eles seriam conduzidos à delegacia, ele voltou atrás e disse que a droga era da adolescente.

Em juízo, o investigador Douglas de Oliveira Lopes, testemunha da acusação, declarou que o setor de investigação da delegacia de Serrana recebeu diversas denúncias de que três indivíduos estariam comercializando drogas na extensão da Rua Nossa Senhora de Fátima, próximo a Rua Vicente de Paula Lima, na cidade e comarca de Serrana. Informou que dois desses três indivíduos eram gêmeos com o nome de

Anderson e Cleber e a terceira pessoa era um indivíduo negro de pronome Welinton. Relatou que as informações diziam que eles revendiam as drogas, moravam em uma residência próxima ao local onde o ato ilícito era cometido e guardavam as drogas na casa da genitora dos gêmeos, na Rua Goiás. Disse que a investigação durou aproximadamente vinte dias, sendo realizadas campanhas nos dois endereços (extensão da Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Goiás), onde foi percebido grande movimentação de usuários de drogas e jovens de bicicletas, indicando que o local era um ponto de drogas. Declarou que a vida pregressa dos acusados também foi investigada, onde foram constatadas algumas anotações policiais, inclusive o envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que a partir daí foi solicitado à autoridade policial para representar pelo mandado de busca que foi deferido. Informou que ele participou das buscas realizadas na Rua Nossa Senhora de Fátima juntamente com uma equipe da polícia militar, não tendo sido encontrado nada de ilícito no local, mas que no endereço da Rua Goiás, na casa da genitora dos acusados, as drogas foram encontradas.

O acusado Anderson Hugo da Costa, em juízo, negou que as drogas encontradas e apreendidas eram dele. Informou que ele morava no endereço da Rua Nossa Senhora de Fátima com sua companheira, mas que não saía de dentro de casa e que as drogas eram de seu irmão, mas que por eles serem gêmeos, foi detido juntamente com seu irmão. Disse que em momento passado foi preso por tráfico de drogas e por ter medo de voltar para cadeia, não ficava com seu irmão. Relatou que no dia do cumprimento do mandado de busca tinha ido até a casa de sua mãe para tomar café, como de costume, tendo se deparado com a polícia quando chegou ao local e que por ser gêmeo de seu irmão, também foi levado preso, mas as drogas encontradas e apreendidas não eram suas, eram apenas de seu irmão Cleber.

O acusado Cleber Fernando da Costa, em juízo, confessou que as drogas encontradas e apreendidas eram dele, não tendo seu irmão nenhuma relação com elas. Relatou que seu irmão Anderson tinha ido até o local dos fatos, momento em que foi surpreendido pelas polícias que se encontravam na residência cumprindo o mandado de busca e foi levado preso junto com ele. Declarou mais uma vez que as drogas eram de sua propriedade e que ele as comercializava, mas que não as vendia no endereço de seu irmão, sendo que os jovens avistados no endereço eram seus amigos que iam até lá para conversar com ele quando ia visitar seu irmão, pois ele, o acusado, estava morando com sua mãe. Informou também que vendia as drogas no endereço de sua genitora (Rua Goiás) e disse que não conhece o Welinton, terceiro citado pelos policiais.

Eis a síntese da prova oral, colhida sob o contraditório, e ela é suficiente para atribuir aos acusados à autoria da conduta criminosa.

Os investigadores da Polícia Civil foram detalhistas e claros ao narrarem toda operação policial. Vale ressaltar que os milicianos, no exercício de sua função, possuem fé pública. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello:

Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

Nesse sentido:

Ementa. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso

de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STF, 6ª T., HC nº 206282 SP 2011/0105418-9).

Consigne-se que não consta que os investigadores tivessem qualquer motivo para acusar os réus injustamente. O elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado, sendo, portanto, inviável a absolvição, pois a prova é sólida e impõe o decreto condenatório no crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Nos termos do art. 33, "caput", da Lei de Drogas, "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar", configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

O artigo 35 do mesmo diploma legal possui a seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.

Para a prática deste tipo legal, basta que haja associação de duas pessoas, contudo, exige-se que este ajuste não seja eventual, mas ao contrário, que haja elementos que denotem a permanência e estabilidade.

Assim sendo, não encontro elementos suficiente e autorizadores para condenação dos acusados pelo crime de associação tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/06, pois, não há como se reconhecer a prática de tal delito. Não há prova da estabilidade e da permanência na prática da traficância capaz de indicar que os réus Anderson e Cleber se encontravam associados de modo permanente. Logo, a imputação quanto ao crime de associação para o tráfico não merece prosperar.

Apesar de ambos os investigadores ouvidos, de forma uníssona e coerente, contarem que em monitoramento aos pontos de venda de drogas nos dois endereços identificaram intensa movimentação de usuários, estando presentes no local os dois acusados, a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, sendo imprescindível a verificação de mínima estabilidade, permanência e vínculo hierárquico entre os agentes, entendimento este sufragado pelo C. STJ e por este Tribunal.

Nesse sentido:

Em contrapartida, não há como se reconhecer a prática do delito de associação para o tráfico, nada obstante o esforço ministerial, pois não houve a demonstração inequívoca do vínculo associativo existente entre os acusados, vínculo este indispensável para a comprovação do crime em questão. Embora o conjunto probatório indique que os réus praticavam a mercancia ilícita junto a terceiros, nenhuma prova foi colhida de forma a atestar, inequivocamente, que mantinham uma associação para a mercancia ilícita. O caso concreto não traz elementos suficientes à caracterização do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe, ainda que, em grau mínimo, certa estabilidade e vínculo hierárquico entre os envolvidos, o que não foi demonstrado no caso concreto. Sobre o assunto, confira: Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se

associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11343/2006. Doutrina. Precedentes. Na espécie, inexistindo a comprovação de que os pacientes e o corréu tiveram o dolo de se associar com estabilidade ou permanência, impossível a sua condenação pelo delito de associação para o tráfico. Precedentes (STJ, Habeas Corpus 440016/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. 07/06/2018).

PELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas - Absolvição do artigo 35, da Lei 11343/06. Tráfico de entorpecentes: Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor. Associação para o tráfico - Absolvição mantida - Animus associativo não configurado - Dúvida razoável. Dosimetria - 1ª fase: Pena-base acima do mínimo, na fração de 1/6, com fundamentação - 2ª fase: Menoridade relativa reconhecida - Pequeno reparo na dosimetria para retorno ao mínimo legal - 3ª fase: Redutor afastado, com justificativa adequada - Considerável quantidade de droga armazenada - Tráfico de cocaína Droga extremamente nociva e de grande lesividade - Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, em 1/6 - Regime fechado mantido - Necessidade de resposta estatal mais enérgica na repreensão do delito - Substituição - Não cabimento - Recurso da defesa parcialmente provido, com reflexo na dosimetria Recurso ministerial improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0015687-28.2012.8.26.0606; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2021; Data de Registro: 20/02/2021). Portanto, a denúncia quanto ao crime de associação para o tráfico não merece prosperar.

Entretanto, a respeito do crime previsto pelo artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, as provas são robustas a despeito da negativa dos réus Anderson e Cleber, sendo que este último chegou a confessar a prática do delito, qual seja, o tráfico de drogas e tentou afastar o seu irmão, mas sem êxito, haja vista que essa afirmação se mostrou isolada nis autos, em total dissonância com o depoimento detalhado dos investigadores da polícia civil que narraram que ambos os irmãos estavam praticando o comercio ilícito de entorpecentes.

Por fim, conclui-se que os réus realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação das penas.

Quanto ao réu ANDERSON HUGO DA COSTA:

Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando as substâncias ilícitas encontradas e a natureza das mesmas (cocaína e crack), por se tratar de substâncias altamente lesivas e viciantes, diferenciando, assim, de outras que não tem especial potencial de adição ou lesividade, o que deve ser sopesado negativamente. Assim sendo, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, considerando a reincidência específica do réu, ocasionada pela condenação definitiva dos autos de nº 0001049-82.2016.8.26.0530 (fls. 71), aumento as penas em 1/6, resultando elas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há incidência da causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de pena 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em face da análise da folha de antecedentes (fls. 73/76), é inviável a aplicação do §4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06.

O regime inicial fechado impõe-se, por expressa disposição legal do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, bem como pela quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu.

Incabível a substituição da pena corpórea ou suspensão condicional da pena em razão do montante de pena aplicado, nos termos dos artigos. 44, inciso I e 77, "caput", do Código Penal.

Quanto ao réu CLEBER FERNANDO DA COSTA:

Sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, considerando as substâncias ilícitas encontradas e a natureza das mesmas (cocaína e crack), por se tratar de substâncias altamente lesivas e viciantes, diferenciando, assim, de outras que não tem especial potencial de adição ou lesividade, o que deve ser sopesado negativamente. Assim sendo, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, apesar de o réu ser reincidente, ocasionado pela condenação definitiva dos autos de nº 0000.961-40.2016.8.26.0596 (fls. 222/231), encontra-se presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual compenso, mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há incidência da causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em face da análise da folha de antecedentes (fls. 78/81), é inviável a aplicação do §4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06.

O regime inicial fechado impõe-se, por expressa disposição legal do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, bem como pela quantidade de pena e reincidência do acusado. Incabível a substituição da pena corpórea ou suspensão condicional da pena em razão do montante de pena aplicado, nos termos dos artigos. 44, inciso I e 77, "caput", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para:

a) CONDENAR o réu ANDERSON HUGO DA COSTA à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixada no patamar mínimo legal (1/3 do salário mínimo vigente à época do delito), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

b) CONDENAR o réu CLEBER FERNANDO DA COSTA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. , fixada no patamar mínimo legal (1/3 do salário-mínimo vigente à época do delito), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

c) ABSOLVER os réus ANDERSON HUGO DA COSTA e CLEBER FERNANDO DA COSTA do delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei. 11.343/06.

Inalterada a situação que ensejou a prisão preventiva, agravada pela condenação, nego o direito de apelar em liberdade.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido, guardando-se apenas o suficiente para eventual contra prova.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.C.

Serrana, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA